

RECURSO CÍVEL Nº 5001593-31.2024.4.02.5113/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANDREA DE SOUZA CALMON CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DII ATESTADA PELO PERITO, EM 2023. AUTORA NÃO IMPUGNOU O LAUDO. BENEFÍCIO REQUERIDO EM 2016, QUANDO INSS ATESTOU NÃO HAVER INCAPACIDADE. NÃO HÁ DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVEM QUE A INCAPACIDADE ESTARIA INSTALADA NAQUELA ÉPOCA. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO PERICIAL. ENUNCIADO 72/TRRJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5001593-31.2024.4.02.5113

510015132598 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001593-31.2024.4.02.5113/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANDREA DE SOUZA CALMON CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença (evento 29) que julgou improcedente o pedido de benefício de auxílio por incapacidade requerido em **01/12/2016**, diante da perda da qualidade de segurado na DII fixada pelo perito judicial (24/07/23).

Sustenta a recorrente (Evento 34) que ajuizou a ação quanto a requerimento com com DER em 2016, período em que tinha a qualidade de segurada. Alega que traz elementos que atestam a doença desde antes da DER, inclusive a negativa do INSS foi através de um pedido de prorrogação de benefício. Requer a reforma da sentença.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, vale lembrar o que dispõe o Enunciado 84/TRRJ:

O momento processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra.

Deste modo, eventuais laudos posteriores não se prestam à análise de eventual incapacidade, devendo ser objeto de apresentação em um novo requerimento administrativo. Em especial quando a documentação é juntada após a sentença, hipótese em que não cabe a apreciação pelo juízo, nos termos do Enunciado 86/TRRJ:

Não podem ser levados em consideração, em sede recursal, argumentos novos, não contidos na inicial e não levados a debate no decorrer do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Na perícia judicial (evento 20), foi constatado ser a parte autora portadora de *J45 - Asma*, o que acarreta **incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, com DII** fixada em **24/07/23**, com fundamento no laudo médico acostado aos autos no evento 1, anexo 5.

De acordo com o CNIS (evento 3, anexo 2), o último período contributivo da autora se estendeu de 01/08/2015 a 31/07/2016, de modo que houve a perda da qualidade de segurado em 16/09/2017, muito antes da DII em 2023.

Inicialmente, tem-se que a autora não impugnou o laudo, de modo que concordou com a DII ali fixada e a questão estaria preclusa. E ainda que assim não fosse, não há comprovação de que ela estaria incapaz em 2017, quando ainda tinha qualidade de segurado, ou seja, 6 anos antes.

Veja-se que a ação só foi ajuizada em 2024, 8 anos após o indeferimento do INSS, de modo que a autora deve arcar com o difícil ônus de comprovar que haveria incapacidade em 2016, quando a perícia do INSS entendeu de modo diverso. E não há nos autos documentos médicos que permitam concluir que a incapacidade estaria presente no ano de 2016 ou mesmo 2017, quando ainda havia qualidade de segurado.

Para fixar a DII em 2023, o perito judicial baseou suas conclusões na anamnese, exame clínico e avaliação dos documentos médicos anexados ao processo e apresentados no dia da perícia médica.

A prova pericial objetiva proporcionar ao juiz os conhecimentos técnicos de sua área que nem juízes e advogados possuem. Somente pode ser afastada caso existam nos autos outros documentos médicos com fortes provas e conclusões superiores àquelas do perito judicial e do INSS. O fato de haver divergência entre as conclusões do perito médico judicial, que, aliás, foram as mesmas do perito médico do INSS, e as eventuais manifestações do médico do segurado, por si só, não compromete a eficácia do laudo produzido em Juízo. Afinal, não se pode perder de perspectiva que, em ações cujo cerne é a incapacidade/capacidade laboral, sempre haverá posicionamentos técnicos divergentes.

De fato, a parte autora, a quem o benefício foi negado administrativamente, alega estar incapacitada para o trabalho por estar doente. Por outro lado, a autarquia, ao negar o benefício, alega a inexistência de incapacidade. Aliás, se assim não fosse, não haveria nem mesmo lide, pretensão resistida. Por conseguinte, para a solução da mesma, mostra-se necessária a realização de perícia médica por *expert* imparcial, nomeado pelo juízo, cujo laudo, obviamente, será contrário às manifestações dos médicos de pelo menos uma das partes.

Cabe lembrar que a Resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) nº 18551/2008 trata da **caracterização de incapacidade laborativa como prerrogativa dos médicos peritos**. Ao médico assistente é dado PRESUMIR a incapacidade de seu cliente. Porém, cabe ao médico perito ATESTAR a capacidade ou incapacidade do examinado para que produza efeitos legais.

Para maior esclarecimento, trago à colação a explicação do perito médico Dr. Alberto Estevez Garcia:

Adredemente, temos que afirmar ao julgador, que MÉDICO PERITO, NÃO É PERITO MÉDICO. O médico que consulta e trata os paciente, mantém um relacionamento de confiança com seus pacientes e este com ele. Ouve com credulidade suas queixas reais e fictícias, acredita nelas, conforta e medica fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Por sua vez, o paciente confia no médico assistencialista e este passa a ser sua âncora, bengala, ao qual faz confidências com certeza do segredo guardado pelo sigilo profissional.

A estes, denominamos de MÉDICO PERITO.

Já o PERITO MÉDICO, não guarda relação com o periciado, apenas o pericia em determinado momento, não guarda qualquer relação com o autor, procura sempre correlacionar, o tipo de enfermidade com sua atividade profissional, daí a importância crucial de ser médico do trabalho e conhecer de profissiografia para a conclusão de capacidade laboral ou incapacidade.

Para concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente, impõe-se comprovação de incapacidade do segurado para suas atividades habituais, temporária ou definitivamente. Importa ressaltar que o simples fato de o segurado do INSS ser portador de determinada doença, sob controle e acompanhamento médico, medicamentoso, fisioterápico e/ou

psicoterapêutico, não implica, por si só, no reconhecimento de efetiva incapacidade para o trabalho. De fato, diversas são as doenças de fundo que acometem milhões de indivíduos, mas cujos sintomas e evolução admitem efetivo controle mediante regular acompanhamento e/ou tratamento médico, sem que gerem incapacidade funcional para o trabalho.

Outrossim, cabe a aplicação do Enunciado 72 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: *“Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trazer razões que possam afastar a higidez do laudo”*.

Portanto, como não foi possível constatar que a incapacidade já estava instalada no momento do requerimento administrativo, é de se manter a DII fixada pelo perito, tal como consta na sentença, que deve ser mantida.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Condenação suspensa, por força do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Submeto a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.**